

第55問

甲は、Aとの間で、自己の所有する自己名義の土地を1000万円でAに売却する旨の契約を締結し、Aから代金全額を受け取った。ところが、甲は、Aに対する所有権移転登記手続前に、Bからその土地を1100万円で買い受けた旨の申入れを受けたことから気が変わり、Bに売却してBに対する所有権移転登記手続をすることとし、Bとの間で、Aに対する売却の事実を告げずに申入れどおりの売買契約を締結し、Bから代金全額を受け取った。しかし、甲A間の売買の事実を知ったBは、甲に対し、所有権移転登記手続前に、甲との売買契約の解除を申し入れ、甲は、これに応じて、Bに対し、受け取った1100万円を返還した。その後、甲は、C銀行から、その土地に抵当権を設定して200万円の融資を受け、その旨の登記手続をし、さらに、これまでの上記事情を知る乙との間で、その土地を800万円で乙に売却する旨の契約を締結し、乙に対する所有権移転登記手続をした。

甲及び乙の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 平成16年度 第2問)

第1 甲の罪責

1 Bに対する売却行為（**論点** 二重譲渡と横領 旧H16-2）

総合 243 頁 論証 114 頁

(1) Aに対する横領罪（252 I）の成否

ア 「自己の占有する他人の物」

本件土地はAの所有にかかるものである。

「占有」とは、濫用のおそれのある支配力を指し、事後的支配のみならず、法律的支配も含む（大判大4.4.9）。

甲は、本件土地の登記名義を保有しているから、法律的支配を有しているといえ、「自己の占有する他人の物」であると認められる。

イ 委託信任関係

条文上明らかではないが遺失物等横領罪の区別の必要性などから、委託信任関係が必要とされる。

甲は、Aへの登記名義の移転に協力する売買契約上の義務を有しているといえるから、委託信任関係も認められる。

ウ 「横領」

横領行為とは、権限を逸脱した不法領得の意思の発現行為であるとされ、判例は、横領罪における不法領得の意思を、「委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければならないような処分をする」意思であると解している（最判昭24.3.8【百選Ⅱ66】）。

本件土地の売却行為は、典型的な不法領得の意思の発現行為であるが、横領罪が成立する（既遂に達する）のは、既遂時期については登記の設定・移転が対抗要件とされている場合については、登記手続の完了時点であると考えられている（最判昭30.12.26参照）。

本問では、移転登記がなされていない以上、この時点では、横領罪は不成立となる（横領罪には未遂犯処罰規定がない。）。

(2) Aに対する背任罪（247）の成否

ア 「他人のためにその事務を処理する者」

上記のように、甲は、Aへの登記名義の移転に協力する売買契約上の義務を有しているといえるが、これは「自己」の義務であるとみることできる。

もっとも、甲にはAによる登記を妨害しないという消極的義務があるとして、「他人」の義務であるとみることができよう（最判昭31.12.7【百選Ⅱ70】参照）。

イ 任務違背行為

他人との信任関係に違背してその財産に損害を加える行為である。

上記義務に違反し、Aとの信任関係に違背して、下記のようにAの財産に損害を加える（おそれがある）ものであって、認められる。

ウ 「自己……の利益を図……る目的」

甲は本件土地の売却代金の差額（100万円）を得ようと考えているから、自己図利目的が認められる。

エ 「財産上の損害」

広く財産的価値の減少を意味し、これは経済的見地から判断すべき（最決昭58.5.24【百選Ⅱ72】）であるとされる。

本問では、所有権移転登記手続が未了であるから、「財産上の損害」は未だ発生しているとは認め難い。

背任罪は未遂に止まる（250）。

(3) Bに対する詐欺罪（246Ⅰ）の成否

一般に、二重譲渡事案においては、第二譲受人は移転登記を備えれば、第一譲受人に対して所有権の移転を対抗し得る（民法177）のであるから、詐欺罪は成立しないと解されている（理論構成としては、欺罔行為における重要事項性、錯誤、財産的損害を否定することが考えられる。）。

もっとも、本問では、Bが後に売買契約を解除していることからすれば、Bが代金を支払った時点で1項詐欺罪の成立を認め得る。なお、Bに対して1100万円を返還していることは、詐欺罪成立後の事情であって同罪の成否には影響しない。

2 C銀行に対する抵当権設定行為

(1) Aに対する横領罪の成否

抵当権設定登記をしていることから、横領罪の成立が認められる。

(2) C銀行に対する詐欺罪の成否

詐欺罪が個別財産に対する罪であることを強調しても、仮にC銀行がAに対する売却を知っていれば融資しなかったという事情が認められず、1項詐欺の成立は否定される。

※ C銀行が金融機関であり、担保価値に細心の注意を払うであろうことを強調すると、仮にAに譲渡されていることを知れば、C銀行は抵当権設定に応じなかったであろうという評価も可能かもしれない。

(3) Aに対する詐欺罪の成否

Aに対する詐欺罪を構成するためには、C銀行を被欺罔者、Aを財産上の被害者とする三角詐欺とみる必要がある。

もっとも、最判昭45.3.26【百選Ⅱ56】は、三角詐欺について被欺罔者に財産上の被害者の財産を処分し得る権能又は地位が必要としているところ、本問では、C銀行にはAの財産を処分する権限がないので、三角詐欺とはいえず、不成立となる。

3 乙に対する売却行為（**論点** 横領後の横領 司H24J1BH16-2）

Aに対する横領罪の成立要件は満たす。

ただ、C銀行への抵当権設定行為に横領罪が成立することにより、その後の処分行為は全て不可罰的事後行為となると解すれば、不成立とも考えられる。

この点に関して、最大判平15.4.23【百選Ⅱ69】は、「委託を受けて他人の不動産を占有する者が、これにほしいままに抵当権を設定してその旨の登記を了した後においても、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、受託者が、その後、その不動産につき、ほしいままに売却等による所有権移転行為を行いその旨の登記を了したときは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をしたものにほかならない。

 総合 245 頁  論証 117 頁

したがって、売却等による所有権移転行為について、横領罪の成立自体は、これを肯定することができるというべきであり、先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならないと解するのが相当である。」としており、少なくとも不可罰的事後行為説に立たないことを明らかにしている。

ただし、同判例は、第2行為のみ起訴された事案であったため、「このように、所有権移転行為について横領罪が成立する以上、先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合における同罪と後行の所有権移転による横領罪との罪数評価のいかんにかかわらず、検察官は、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮し、先行の抵当権設定行為ではなく、後行の所有権移転行為をとらえて公訴を提起することができるものと解される。また、そのような公訴の提起を受けた裁判所は、所有権移転の点だけを審判の対象とすべきであり、犯罪の成否を決するに当たり、売却に先立って横領罪を構成する抵当権設定行為があったかどうかというような訴因外の事情に立ち入って審理判断すべきものではない。このような場合に、被告人に対し、訴因外の犯罪事実を主張立証することによって訴因とされている事実について犯罪の成否を争うことを許容することは、訴因外の犯罪事実をめぐる、被告人が犯罪成立の証明を、検察官が犯罪不成立の証明を志向するなど、当事者双方に不自然な訴訟活動を行わせることにもなりかねず、訴因制度を採る訴訟手続の本旨に沿わないものというべきである。」と述べており、罪数関係については明らかにしていない。

下級審判例には、包括一罪として処理するものがある（大阪地判平20.3.14）。

なお、乙に対する詐欺罪については、乙は事情を知っていることから、錯誤ひいてはこれを招来するような危険性を有する欺罔行為が認められず、不成立となる。

第2 乙の罪責

横領罪の共同正犯（60）の成否が問題となる。

この点については、単純悪意者は共犯とならないが、背信的悪意者であれば共犯となると解する立場が一般的である（福岡高判昭47.11.22【百選Ⅱ65】、最判昭31.6.26）。

この立場に従えば、乙は背信的悪意者に当たらない限り、横領罪の共同正犯とはならない。なお、単純悪意者には狭義の共犯すら成立させるべきではない。

（法務省発表の出題趣旨）

本問は、土地の二重売買、その後の抵当権設定及び更なる売却に関わる事例を素材として、売主及び情を知って買い受けた者の罪責を問うものである。ここでは、横領罪、詐欺罪等の成立要件の理解、横領後の横領に関する的確な考察が重視されるとともに、事例を法的に分析して論理的に首尾一貫した論述を行うことが求められる。

答案構成

第 1 甲の罪責について

1 B に対する売却行為 横領罪の成否 (252)

↓
「占有」 (法律上の占有も含む)
↓
委託信任関係
↓
「他人の物」
↓
「横領」 (権限を逸脱した不法領得の意思の発現行為)
↓
登記移転時
↓
A に対する背任未遂罪 (250、247) 成立
↓
B に対する詐欺罪 (246 I) の成否
↓
原則不成立
↓
本問では成立

2 C 銀行に対する抵当権設定行為 横領罪成立

↓
C 銀行に対する詐欺罪不成立
↓
A に対する詐欺罪の成否
↓
被欺罔者が財産上の被害者の財産を処分する権限を有する必要がある
↓
あてはめ
↓
不成立

3 乙に対する売却行為 横領後の横領

↓
可罰説
↓
包括一罪となる (背任未遂罪も包括評価、B に対する詐欺罪とは併合罪)

第2 乙の罪責について

1 横領罪の共同正犯（60）の成否



背信的悪意者であるような特別の事情がある場合のみ成立



2 共犯と身分



65条1項が適用される

第1 甲の罪責について

1 Bに対する売却行為

(1) まず、甲が既にAに売却した土地を、Bに売却した行為は、Aに対する横領罪（252条1項）を構成し得る。

ア 「占有」については法律上の占有も含まれると解するところ、登記名義人の甲には「占有」が認められる。

イ 甲は売買契約に基づきAのために本件土地の保管義務を負っているから、委託信任関係も認められる。

ウ 本問では既に代金が支払われている以上、Aには確定的に所有権が移転しており、かかる所有権は刑法的保護に値するものといえるので、本件土地は「他人の物」に当たる。

エ 「横領」とは、権限を逸脱した不法領得の意思の発現行為である。不動産の二重譲渡においては、第二譲受人が登記を具備した時点で、初めて実質的な財産上の利益侵害が発生する。そうだとすれば、この時点で、不法領得の意思が確定的に発現する。

したがって、「横領」と認められるのは、登記移転時である。

本問では、未だ登記移転はないので、「横領」は認められない。

横領罪には未遂犯処罰規定がないので、結局横領罪は成立しない。

(2) もっとも、背任未遂罪（250条、247条）は成立する。すなわち、甲はAの移転登記を妨害しないという消極的義務を負うから、「他人の……事務を処理する者」に当たり、標記行為は、上記義務に違反し、Aとの信任関係に违背して、Aの財産に損害を加えるおそれ

1

があるものであるから、任務違背行為も認められる。また、甲は本件土地の売却代金の差額を得ようと考えているから、「自己……の利益を図……る目的」も認められる。もっとも、本問では、所有権移転登記手続が未了であるから、「財産上の損害」は未だ発生していない。

(3) 続いて、甲が甲A間の売買の事実を秘して、本件土地をBに売却した行為について、「人を欺いて財物を交付させた」ものとして、詐欺罪（246条1項）の成否が問題となるも、第二譲受人Bは、所有権を取得できるから、原則として損害はなく、詐欺罪は成立しない。

ただし、Bが、Aの存在を知っていたら買わなかっただろうと考えられる特別の事情がある場合は、例外的に詐欺罪が成立する。この場合は、実質的にみて財産上の損害が認められるからである。

本問では、Bは甲A間の売買の事実を知った後、甲との売買契約の解除を申し入れている。そうすると、BとしてはAの存在を知っていたら買わなかったであろうと認められ、前記特別の事情がある。

したがって、甲はBに対する詐欺罪の罪責を負う。なお、Bに対して1100万円を返還していることは、詐欺罪成立後の事情であって同罪の成否には影響しない。

2 C銀行に対する抵当権設定行為

(1) 甲がC銀行に対して抵当権を設定し、登記手続をした行為は横領罪（252条1項）を構成する。すなわち、上記と同様に、「占有」、委託信任関係及び「他人の物」という要件は満たされる。また、他人の不動産について抵当権を設定し、その登記手続を完了することは、不法

2

領得の意思の確定的な発現といえ、「横領」といえる。

(2) 一方、C銀行に対する詐欺罪は成立しない。C銀行に対する抵当権設定登記手続は完了しており、また、上記特別の事情も認められず、C銀行には財産上の損害が認められないからである。

(3) では、Aに対する詐欺罪が成立しないか。

本件抵当権設定行為によって欺罔されているのはC銀行である。本件でAを被害者とする詐欺罪が成立する場合、被欺罔者と被害者が異なる三角詐欺となるが、三角詐欺が成立するためには、被欺罔者が財産上の被害者の財産を処分する権限を有する必要がある。

しかし、C銀行にはAの財産を処分する権限は認められない。

よって、Aに対する詐欺罪は成立しない。

3 乙に対する売却行為

(1) 甲が乙に対して、本件土地を売却した行為が、重ねてAに対する横領罪に当たらないか。

この点に関して、本件土地については、既にC銀行に対して抵当権設定登記手続を完了した時点で横領罪が成立している。そして、横領罪は状態犯であるから、一旦横領罪が成立した財物を更に処分する行為は不可罰的事後行為となるにすぎないとも考えられる。

しかし、不可罰的事後行為なる概念を認める趣旨は、先行行為により後行行為の違法性が評価されているとみることができる点に求められるところ、担保の設定と所有権の移転では権利侵害の質に違いがある以上、先行行為で後行行為を評価しているとみることができない。

3

したがって、売却行為は別途横領罪を構成する。

もっとも、両行為は、同一の物に対する侵害であるから、包括一罪として処理すべきであると考ええる。なお、上記背任未遂罪も同様に包括評価すべきである。Bに対する詐欺罪とは併合罪関係となる。

(2) 次に、乙に対する詐欺罪が成立しないかが問題となるも、乙は事情を知っているので、錯誤ひいてはこれを招来する危険性を有する欺罔行為の存在が認められず、詐欺罪は成立しない。

第2 乙の罪責について

1 乙は、事情を全て了知した上で、土地を買い受けており、「二人以上共同して犯罪を実行した」ものとして、横領罪の共同正犯（60条）が成立しないか。

この点に関して、乙が単純悪意者であれば、民法が許容する自由競争の範囲内といえるので、横領罪の共同正犯は成立しない。他方、乙がAに損害を加えようとする等、背信的悪意者であるような特別の事情がある場合には、横領罪の共同正犯が成立する。

2 なお、その場合には、乙は非身分者であるが、65条1項により共同正犯の罪責を負うと解する。横領罪は、委託信任関係に基づいて他人の物を占有する者のみが犯すことができる真正身分犯であるところ、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」との文言から真正身分犯には同項が適用され、また、非身分者であっても、身分者に加功することによって、法益侵害の危険を惹起することができるため、「共犯」には共同正犯を含むと解すべきだからである。

以上

4